



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 273/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

התובעים: 1. בנימין יפה
2. רונית בן בסט
ע"י ב"כ עוה"ד דוד שוב
מרחוב חבקוק 7 תל אביב

נגד

הנתבע: עמית ארד
ע"י ב"כ עוה"ד עודד פרץ
מרחוב הלפרין ירמיהו 5 נתניה

פ ס ק ד י ן

מבוא

הסכסוך דנן עניינו בבית שברחוב לינקולן 14 תל אביב הבנוי על חלקה 75 בגוש 7130 (להלן: "הבית").

התובעים הינם בעלים של דירות בבית.

הנתבע הינו בעלים של דירה בקומת הקרקע של הבית הידועה כתת חלקה 4.

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

התובעים טוענים כי בין השנים 2005-2006 ביצע הנתבע שיפוצים בדירתו במסגרתם שבר קיר חיצוני של הבית, ביטל את הכניסה לדירתו מחדר המדרגות והכשיר כניסה פרטית דרך חצר הבית. לטענת התובעים הנתבע הרס קירות חדר בדירתו והתקין ויטרינות שקופות עם דלת כניסה ראשית לבית ודלתות יציאה לחצר. כן בנה הנתבע גרם מדרגות ומשטח מרוצף ב"כניסה הפרטית" שיצר. עוד טוענים התובעים כי הנתבע עושה שימוש ייחודי בחצר המשותפת הסמוכה למרפסת דירתו והוא אף מחזיק בה כלב מאיים אשר מונע כניסה של בעלי הדירות האחרים לחצר.

לאור האמור מבקשים התובעים כי ינתן סעד המחייב את הנתבע להסיר את הויטרינות שהתקין ויבנה במקומם קירות, כפי שהיה קודם לכן, ללא דלתות חיצוניות וכן יסלק את גרם המדרגות ויחזיר את מצב הרכוש המשותף לקדמותו.

הנתבע טוען בכתב ההגנה מטעמו כי לא שבר כל קיר חיצוני ולא בנה גרם מדרגות, כי דלת הכניסה מחדר המדרגות קיימת וכי לא הכשיר כניסה פרטית כנטען. הנתבע טוען כי לא יצר מרפסת חדשה ולא יצר ויטרינות ואין הוא עושה כל שימוש ייחודי בחצר המשותפת אשר פתוחה לכל דיכפין. לנתבע אומנם יש



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 273/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

כלב אך הוא אינו מוחזק בחצר המשותפת ובודאי שאינו מונע גישה אליה. לטענת הנתבע התביעה מקורה בסכסוך שכנים ומטרתה אך נקמנות גרידא.

ביום 20.09.10 ערכתי ביקור במקום.

ביום 17.01.11 נתקיימה ישיבת הוכחות ולאחריה סיכמו הצדדים את טיעוניהם בעל פה.

מטעם התובעים העידו התובעים בעצמם וכן גב' נטי גולן – בעלת הדירה בקומת הקרקע הסמוכה לדירת הנתבע וגב' רבקה מנדלבאום בעלת הדירה שמעל לדירת הנתבע.

מטעם הנתבעים העידו הנתבע ורעייתו – נעמה ארד, וכן גב' נעמי בצר – בעלת דירה בקומה השלישית בבית וגב' יעל שלמון ברנע – שוכרת דירת הגב' מנדלבאום.

דיון

ניתוח הראיות

ראשית, לממצאים עובדתיים רלבנטיים כפי שנתבררו במהלך הביקור שנערך במקום ביום 20.09.10.

לדירת הנתבע כניסה מחדר המדרגות של הבית.

מרפסת דירת הנתבע סגורה בחלונות ויטרינה מקצה מעקה המרפסת עד לגובה התקרה, למעט רחבה של כ- 2 מ"ר בצידה הימני של המרפסת (כשנמצאים עם הפנים מתוך הדירה כלפי החצר). אין כל שטח מרוצף בחצר הבית הסמוכה למרפסת דירת הנתבע.

בחזית המרפסת מעקה נמוך מבטון המונמך במרכזו עד לגובה הרצפה ומותקנות בויטרינה 2 דלתות מזכוכית המאפשרות יציאה ישירה לגינה.

בצידה הימני של הויטרינה מותקנת דלת ממנה יציאה לחלק מהמרפסת בגודל של 2 מ"ר שאינו סגור בקירות. בקצה הימני של המרפסת המעקה הונמך לגובה הרצפה וישנן מדרגות המאפשרות ירידה לחצר.

מהתיאור שלעיל עולה כי לדירת הנתבע, למעשה, 3 כניסות – אחת מחדר המדרגות, השניה דרך מדרגות ודלת בצידה הימני של המרפסת והשלישית דרך דלתות ויטרינה בחזית המרפסת.

חצר הבית פתוחה וניתן להכנס אליה דרך שביל הכניסה לבית. בחצר הבית צמחיה וכן מותקן ערסל בין העצים. חצר הבית פתוחה לכל הכיוונים וניתן לעבור ממנה לחצר הסמוכה לדירת השכן וכן לשביל היקפי של הבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 273/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

בדירה הסמוכה לדירת הנתבע המרפסת סגורה בחלונות אלומניום וסורגים עד לגובה התקרה, מעקה הבטון רצוף לכל אורך המרפסת ואין ירידה מהמרפסת ישירות לחצר. גובה מעקה הבטון זהה לגובה מעקה הבטון במרפסת דירת הנתבע.

מהעדויות שנשמעו בפני עולה כי אין מחלוקת כי הנתבע ביצע עבודות שיפוץ בדירה בשנת 2005 (עמוד 16 לפרוטוקול שורה 25). מעדותו של הנתבע עולה גם כי הוא זה אשר התקין את הויטרינה במרפסת ואת הדלת המותקנת בה (עמוד 17 לפרוטוקול שורות 5 ו-8 ומוצג ת/2).

בעדותו ניסה הנתבע לטעון כי עובר לשיפוץ המרפסת היתה פתוחה ולכאורה היתה גישה ממנה ואליה מהחצר. אין בידי לקבל גרסתו זו של הנתבע.

מהעדויות שנשמעו בפני מתברר כי עובר לביצוע השיפוץ על ידי הנתבע מרפסת דירתו היתה סגורה - הנתבע עצמו מעיד כי המרפסת היתה סגורה בתריסי הזזה אותם החליף בויטרינות המותקנות כיום (עמוד 17 לפרוטוקול שורות 4 ו-7 עד 8). גם הגב' מנדלבאום מעידה כי עובר לעבודות היו במרפסת תריסי רפרפות ממעקה הבטון עד לתקרה (עמוד 12 לפרוטוקול שורות 7-8) וכי לא היתה יציאה מהדירה לחצר (עמוד 10 לפרוטוקול שורה 30).

הגב' גולן שהינה, כאמור, בעלת הדירה הסמוכה לדירת הנתבע, מכירה את הבית מאז שנת 1960 ומעידה "במצב המקורי היו חלונות מסוף המעקה ועד התקרה. ש.ת. מעולם זה לא היה בנוי בטון כמו שזה זה המצב המקורי" (עמוד 10 לפרוטוקול שורות 11-12). גם מר יפה מעיד בהקשר זה "זה היה סגור בדומה לדירה השנייה" (עמוד 6 לפרוטוקול שורה 15).

גם המצב העובדתי של גדר הבטון מלמד כי אין המדובר בבניה מקורית אלא בתוספת מאוחרת. ניכר בבירור כי סף המעקה שונה ואיננו הסף המקורי (כפי שניתן לראות בדירה השכנה במוצג ת/1) והותקנו לוחות שיש לתיחום קצוות המעקה החדשים (מוצג ת/2).

ממכלול העדויות כאמור אני קובע כי עובר לביצוע העבודות על ידי הנתבע בדירתו לא היתה גישה ישירה ממרפסת הדירה אל החצר.

מסקנה עובדתית זו גם מתחזקת לאור תשריט הבית המשותף, המצוי בידיעתי השיפוטית, ממנו ניתן להיווכח כי בעת רישום הבית לא היו במרפסת דירת הנתבע פתחים או מדרגות במקומות בהם הם נמצאים כיום. במיוחד אמורים הדברים כאשר המדובר בתובענה דנן בהליך בפני מפקח על רישום מקרקעין אשר עליו לחרוץ את דינו על פי המצב הרישומי הקיים (רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אוננו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י לח (4) 487).

זאת ועוד. מעבר לעדותו, שגם היא איננה חד משמעית כאמור, הנתבע לא הביא כל עדות אחרת להוכחת טענתו לפיה היתה ירידה ישירה לחצר לפני ביצוע העבודות על ידו. גב' ארד (עמוד 15 לפרוטוקול שורה 7) וגב' שלמון (עמוד 14 לפרוטוקול שורות 14 – 17) לא הכירו את הדירה במצבה הקודם. הגב' בנצר לא זכרה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 273/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

כיצד נראתה הדירה לפני השיפוץ (עמוד 13 לפרוטוקול שורות 17-19). בהקשר זה יכול היה הנתבע להביא לעדות, למשל, את הקודמים לו בזכויות, אך הוא לא עשה כן, ללא כל הסבר.

ההלכה קובעת בהקשר זה כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606).

בנוגע למדרגות המותקנות אין כל עדות של מי מהעדים בדבר קיומן עובר לביצוע העבודות על ידי הנתבע. זאת ועוד. מעדותו של הנתבע עולה גם כי עובר לשיפוץ הוא לא התגורר בדירה ולא נכנס אליה ואין הוא יודע מהיכן נכנסו בעלי הדירה הקודמים לו בזכויות (עמוד 17 לפרוטוקול שורות 25-26). שילוב עדותו זו עם עדותו כאמור כי הוא זה שהתקין את הדלת במרפסת ובצירוף עם הקביעה העובדתית האמורה כי עובר לביצוע העבודות בדירת הנתבע מרפסת הדירה היתה סגורה, מובילים למסקנה כי המדרגות הותקנו על ידי הנתבע במסגרת שיפוץ דירתו. יוער כי גם מדרגות אלו אינן מופיעות בתשריט הבית המשותף הרשום.

נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") והוא מוטל על שכמה של התובעת בבחינת הכלל הידוע "המוציא מחברו עליו הראיה" (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי – קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333).

מהראיות שלעיל עולה כי לא עלה בידי התובעים להוכיח חלק מרכזי מן הטענות העובדתיות שנטענו על ידם - דלת הכניסה לדירה מחדר המדרגות לא נסגרה והיא עודנה קיימת וממנה גישה לדירת הנתבע. גם לא הוכח כי במקום בו מותקנת ויטרינה היה בעבר קיר שנפרץ על ידי הנתבע. כך גם לא הוכח כי הויטרינות הותקנו במקום שונה מזה שבו היו תריסי הרפפה קודם לכן.

אולם, כן עלה בידי התובעים להוכיח כי הנתבע הוא זה אשר פרץ את גדר הבטון של המרפסת ופתח בה 2 פתחים - האחד בחזיתה ובו מותקנת דלת הויטרינה והשני הצד המרפסת היכן שהותקנו על ידי הנתבע גם מדרגות ירידה ישירה לשטח החצר.

המצב המשפטי

הקירות החיצוניים של דירת הנתבע, ובכלל זה גדר הבטון במרפסת הדירה, לא הוצמדו לדירה על פי הרשום בפנקס הבתים המשותפים. משכך, בהתאם להוראת סעיף 55 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), קירות אלה מהווים רכוש משותף של הבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 273/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

המסגרת החוקית לדיון בענייננו קבוע בסעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין החל על הבית כאמור, הקובע כי:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזונו החיצוני התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."

בע"א 136/63 לווינהיים ואח' נ. שוורצמן ואח' פ"ד י"ז (3) 1722 בעמ' 1725 נפסק כי "אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל הסכמת האסיפה הכללית ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפצויי נאות או לא".

בע"א 515/65 רבובסקי ואח' נגד גלסברג ואח' פ"ד כ (2) עמ' 290 כי פגיעה ברכוש המשותף מצדיקה מתן צו עשה גם מבלי שיתלווה לפגיעה כל נזק ממשי.

ההלכות המוזכרות לעיל אושרו גם בע"א 93/81 אליאס ואח' נ. שיפר ואח' פ"ד ל"ז (2) 444.

פסיקה זו מצמצמת את יכולת הפגיעה של בעל דירה ברכוש המשותף.

זאת ועוד. בע"א 395/74 יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח' פ"ד כט (2) 39 נקבע כי "המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק-דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית-המשפט המחוזי באמרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם".

יוצא כי פתיחת פתח בקיר משותף מהווה פגיעה ומשכך, הרי שגם פתיחת מעקה הבטון ויצירת יציאות ישירות מדירת הנתבע לחצר המהווה רכוש משותף, הינה פגיעה ברכוש המשותף הדורשת את הסכמת בעלי הדירות בבית, הסכמה שלא נטען וממילא לא הוכח, כי נתקבלה במקרה דנן.

מעבר לאמור, המשמעות, למעשה, של יצירת הפתחים כאמור, הינה יצירת גישה ישירה לחצר הבית ושינוי מבני מהותי כך שהכניסה לדירת הנתבע הינה מהחצר המשותפת. טבעם של דברים הוא שכאשר קיימים פתחי יציאה ישירים לחצר, דוגמת הפתחים במקרה דנן, השימוש על ידי בעלי דירות האחרים בחצר הולך ופוחת.

למעשה, יצירת הפתחים הופכת את דירת הנתבע, שלא כדין, לדירה עם כניסה פרטית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 273/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

אין הנתבע יכול להיבנות בהגנתו על כך כי, לטענתו, העבודות האמורות בוצעו לפני שנים.

אי התנגדות של שכנים לעבודות, אף אם נעשו לפני שנים, אין בה די כדי להוות הסכמה לשימוש. שתיקה כזו, ככל שהיתה, מקימה לנתבע רשות שימוש הדירה אשר ניתנת להפסקה בכל עת על ידי המעניק אותה. משהוגשה התובענה דנן הביעו בברור חלק מבעלי הדירות את רצונם להפסקת השימוש על ידי הנתבע (מיגל דויטש קניין (תשנ"ט, כרך ב') עמ' 414, רע"א 6339/97 דוקר ואח' נ' סלומון ואח' פד"י נח (1) 199 וע"א (ת"א) 2816/03 ציפורה קונצ'יצקי ואח' נ. דליה שפולן ואח' תק-מח 2006 (2), 991).

הנתבע גם לא עמד בנטל להוכיח כי רשות השימוש שניתנה לו, לטענתו, מכח שתיקת בעלי הדירות, הינה רשות שימוש בלתי הדירה. ההפך הוא הנכון. מעדותה של הגב' בנצר עולה כי התובעים התנגדו לפעולות הנתבע מההתחלה – "אין סיכוי שהתובעים הסכימו, הם בסך הכל שני דיירים נמתו 20 דירות אני זוכרת שהם היו נגד מהתחלה" (עמוד 13 לפרוטוקול שורות 24-25).

כך גם אין בידי הנתבע גם להיבנות בהגנתו מטענת השיהוי.

ההלכה בהקשר זה קובעת כי "כאשר נטען כי תביעה הוגשה תוך שיהוי בוחן בית המשפט את ההשתתחות שבהגשת התביעה - קרי, את משך הזמן שחלף מהמועד בו קמה עילת התביעה ועד המועד שבו הוגשה התביעה. במובן זה דומה בדיקת טענת השיהוי בהגשת תביעה לבדיקת השאלה האם התיישנה התביעה. ואולם, בשונה מטענת התיישנות, לא די בכך שחלף פרק זמן ממושך ממועד קום העילה ועד הגשת התביעה בכדי שתקום טענת שיהוי. שיהוי בהגשת תביעה נוצר מקום בו יש בהשתתחות בפנייה לבית המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע שלא להיתבע. לפיכך, בכדי שייקבע כי תביעה הוגשה בשיהוי על הנתבע להוכיח כי בנסיבות המקרה התובע זנח את זכות התביעה; או כי במשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה; או כי השיהוי נגרם עקב חוסר תום לב מצד התובע (ראו, ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד נז(5) 433 (להלן - פרשת תלמוד תורה); ע"א 410/87 עזבון ליברמן נ' יונגר, פ"ד מה(3) 749, 756-755; ע"א 403/63 תמיר נ' שמאלי פ"ד יח(1) 47, 53-54) " (רע"א 8630/05 נ"ר שיתופי - אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ ואח' נ' עיריית הוד השרון (טרם פורסם)).

לאור המבחנים האמורים הרי שטענת השיהוי שנטענה על ידי הנתבע לא הוכחה על ידו.

מעדות התובעים עולה גם כי הם פנו בדרישות לנתבע, לעיריית תל אביב בתלונה בדבר פעולות הנתבע, ואף לאגודה לתרבות הדיור בשנים 2008 ו- 2009 (עמוד 7 לפרוטוקול שורות 12-15). התובעים גם פנו אל הנתבע בשנת 2009 בדרישה להסיר גדר שהתקין בחצר וזו אכן הוסרה (עמוד 4 לפרוטוקול שורות 20-21). הזמן שחלף בין ביצוע העבודות לבין דרישות התובעים להשבת המצב לקדמותו לא היה ארוך מספיק להצדיק קבלת טענת השיהוי ולא ניתן, בנסיבות אלה, לראות את התובעים כמי שלא עמדו על זכויותיהם, נהגו בחוסר תום לב או זנחו את תביעתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 273/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

זאת ועוד. גם אם נקבל טענת הנתבע כי היה שיהוי כלשהו בהגשת התביעה ע"י התובעים, הרי שלא הוכח כי נגרם לנתבע נזק כלשהו עקב שיהוי זה. ראשית, העבודות בוצעו על ידי הנתבע מכלתחילה עוד בטרם נכנס לדירתו. אף לו היו פונים התובעים בהליך מוקדם יותר, הרי שהעבודות כבר נעשו והושלמו על ידי הנתבע וממילא, "הנזק" כבר נגרם. קבלת טענת הנתבע בהקשר זה תחייב מסקנה בלתי מסתברת כי בכל מקרה שבו לא ננקט הליך זמני על ידי תובעים, הם יהיו מושחקים מלטעון מאוחר יותר כנגד הסגת הגבול, בשל גרימת נזק לנתבע עקב השלמת העבודות על ידו. שנית, במקרה דנן גם לא נגרם לנתבע כל נזק עובדתי, שכן, לטענת הנתבע נותרה הכניסה לדירתו מחדר המדרגות המשותף והוא עושה גם בה שימוש (עמוד 17 לפרוטוקול שורה 24). וראה גם עדותה של הגב' ארד, אשתו של הנתבע, לפיה "אני נכנסתי לעיתים דרך חדר המדרגות ולעיתים מבחוץ. ש.ת. אורחים נכנסים לעיתים ככה ולעיתים ככה" (עמוד 15 שורות 9-10). ברי מעדויות אלו כי הפתח המקורי מחדר המדרגות עודנו שמיש. אף במהלך הביקור במקום נכנסתי לדירת הנתבע דרך הכניסה שבחדר המדרגות.

ככל שעשה הנתבע שינויים מאוחרים בדירתו, לרבות כאלו לאחר הגשת התביעה והביקור שנערך במקום, הרי שהאחריות לעניין זה מוטלת על כתפיו בלבד ואין בכל פגיעה אפשרית בו עקב כך להצדיק את דחיית התביעה כנגדו.

בהקשר זה יוער כי לצורך ההכרעה בתובענה דנן אין כל משקל לשאלה אם העירייה נקטה בהליכים משפטיים כנגד הנתבע, אם לאו. הרשות העירונית פועלת בהתאם לדיני התכנון והבניה וההליכים שמנוהלים על ידה הינם הליכים פליליים. במסגרת זו, "העדר עניין לציבור", למשל, מהווה הצדק לאי נקיטת הליכים משפטיים. לעומת זאת, ההליכים שבפני המפקח על רישום מקרקעין הינם הליכים אזרחיים בדבר זכויותיהם הקנייניות של הצדדים. ככל שיש בפעולות הנתבעת פגיעה בזכות קניינית של בעלי הדירות, הרי, שהינם זכאים להגנה על זכותם.

לאור האמור גם אין בידי לקבל את טענות הנתבע בדבר מאזן הנוחות אשר מחייב, לטענתו, הותרת הפתחים במקומם.

אומנם, ההלכה שנפסקה בע"א 810/82 זול בו בע"מ נגד זיידה ואח' פ"ד ל"ז (4) 737, בכל הנוגע ליחסים בין בעלים במקרקעין משותפים היא כי ניתן להחילה גם על יחסים שבין בעלי דירות בבית משותף. כדברי כב' השופט ברק (כתוארו אז) שם (בעמ' 740): "בעלותו של שותף במקרקעין אין בה כשלעצמה "כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר" (סעיף 14 לחוק המקרקעין). הסייג השני קובע, כי הן הרוב והן המיעוט חייבים לפעול בדרך מקובלת ובתום לב (סעיפים 39 ו-61 (ב) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973. המיעוט והרוב אינם זרים זה לזה. עבותות של קניין מקשרים ביניהם. חוק המקרקעין מעניק לכל אחד מהם כוחות כלפי רעהו. בהפעלת כוחות אלה יש לנהוג בהגינות".

כך גם פוסק כב' השופט ח. כהן פסק בע"א 782/70 רדומילסקי נגד פרידמן פ"ד כה (2) 523 בעמ' 530: "ובא הכלל הגדול שבסעיף 14 לחוק וקובע שזכות הבעלות כשלעצמה אין בה כדי להצדיק עשיית כל דבר, ומתן צו-מניעה בכלל זה, "הגורם נזק או אי-נוחות לאחר" – רוצה לומר, אין להתיר את השימוש בזכות הבעלות כעילה לגרוע נזק או אי-נוחות אפילו למסיג-גבול, מקום שהשימוש בעילה זו אינו דרוש באורח סביר למימוש זכות הבעלות עצמה או למטרה חוקית אחרת."



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 273/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

גם כב' השופט חשין ברע"א 7112/93 צודלר ואח' נ. ש. יוסף ואח' פ"ד מח (5) 550, החיל את עיקרון "תום לב" על יחסי בעלי דירות בבית משותף.

וראה גם רע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נגד משה סלומון ואח' פד"י נה (1) 199.

אולם, החלת ההלכות האמורות על המקרה דנן איננה מובילה לטעמי למסקנה כי יש להותיר על קנה את הפגיעה ברכוש המשותף במקרה דנן.

המדובר בפגיעה בזכות במקרקעין של התובעים, בעלי דירות בבית, שעוצמתה איננה חלשה. הותרת פתחי היציאה הישירה מביאים, כאמור, להפיכתה בפועל של דירת הנתבע לדירה עם כניסה פרטית ישירה מחצר הבית, "על חשבון" זכות הקניין ברכוש המשותף של בעלי הדירות בבית. ויודגש, אין המדובר רק בפגיעה הפיזית בגובה גדר המרפסת, שאז יתכן ומאזן השיקולים היה שונה, אלא בכך שהותרת יציאות ישירות מהדירה לחצר הופכות את השימוש בחצר מניה וביה למוגבל לבעלי הדירות האחרים בבית מחד, ומ"נכסת" לדירת הנתבע חלק מהרכוש המשותף בבחינת דירת גן עם כניסה פרטית מאידך.

כאמור לעיל גם לא התרשמתי כי תהיה פגיעה משמעותית בנתבע לאור הסרת הפגיעה, שכן, ממילא, הכניסה לבית אפשרית, ובפועל מבוצעת, על פי העדויות שלעיל והביקור במקום, גם מחדר המדרגות של הבית. מכל מקום, אף אם יש בסילוק הפגיעה מידה מסויימת של אי נוחות לנתבע, אין בכך להכשיר ולהצדיק פגיעה בזכויות קניין של בעלי הדירות האחרים בנסיבות אלה.

בנוסף, קיים גם חשש כי פעולת הנתבע ביצירת גישה ישירה מדירתו לחצר הבית עשויה להביא לכך שגם אחרים יבקשו לבצע פעולות כנ"ל ברכוש המשותף לטובתם האישית. כך פוסק בית המשפט העליון בעניין זה: "אם תותר הרצועה, ובית המשפט יתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאוי הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם" (בע"א 93/81 אליאס נ. שיפר לז (2) 444).

אומנם התרשמתי כי, במיוחד בכל הקשור לתובעת, הסכסוך שבין הצדדים מקורו בנושאים אחרים ויש מידה של "עין תחת עין" בעצם הגשת התביעה כנגד הנתבע. אולם, אין די בכך, במכלול השיקולים כאמור, כדי להצדיק שלילת הסעד המותרת פגיעה בזכויות במקרקעין על קנה.

השימוש בחצר

בכל הקשור לשימוש בחצר המשותפת לא עלה בידי התובעים להוכיח כי הנתבע עושה שימוש ייחודי באותה חצר.

לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 273/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתובה (ראה: עו"ד ע. כהן, בתים משותפים בניה, שימוש וניהול הרכוש המשותף (תשס"ד) בעמ' 48).

התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

השימוש בחצר כמקום למפגש ובילוי הינו שימוש סביר ורגיל על פי תנאי הזמן והמקום ואף על פי כוונת בעלי הדירות בבית עצמם. כך מעידה התובעת (עמוד 5 לפרוטוקול שורה 20). כך גם מעידות הגב' בנצר (עמוד 12 לפרוטוקול שורות 29-30 ועמוד 13 לפרוטוקול שורה 20) והגב' שלמון (עמוד 14 לפרוטוקול שורות 5-9).

כאמור, לא הוכח כי נעשה על ידי הנתבע כל בינוי בחצר הבית ובהקשר זה טענות התובעים מתמצות בארבע - תחושת חוסר הפרטיות בגינה עקב גישה ישירה מהדירה לגינה וחלונות הויטריה, שתילת צמחיה על ידי הנתבע בחצר, התקנת ערסל וקשירת הכלב בשטח החצר.

בכל הקשור לטענת "חוסר הפרטיות" עיקר טענות התובעים הן כי ישנה יציאה ישירה מדירת הנתבע לחצר (אליה התייחסנו כבר לעיל) וכי קירות מרפסת דירתו הינם מזכוכית. עניינים אלו גורמים לתובעים תחושה של חוסר פרטיות בעת שהייתם בחצר. אולם, אין בתחושת התובעים כדי להצדיק איסור שימוש סביר על ידי הנתבע בשטח החצר.

ראשית, המדובר בחצר משותפת ולכן, ממילא, לא ברור איזו "פרטיות" מבקשים לעצמם התובעים באותה חצר.

שנית, קיומה של המרפסת הסגורה בדירת הנתבע הינו דבר קיים מימים ימימה כאמור לעיל. משכך, אין בהחלפת תריסי ההזזה הישנים בחלונות הויטרינה הנוכחיים משום פגיעה בתובעים או ברכוש המשותף של הבית. הפגיעה הנטענת באפשרות השימוש בחצר, מעצם קיומה של מרפסת סגורה בויטרינה בדירת הנתבע, זהה לפגיעה אפשרית מהמרפסת בדירה השכנה (שעודנה בנויה על פי מצבה המקורי). זהו המצב המקורי של הבית ולא ניתן לשנותו או לפגוע בזכויות קניין של הנתבע אך בשל "תחושות" אי הפרטיות של התובעים.

כך גם לא מצאתי כל ממש בטענות התובעים (שלא הוזכרו כלל בכתב התביעה) בדבר השתלטות הנתבע על רכוש משותף בעצם שתילת צמחיה בשטח הגינה. הצמחיה שנשתלה איננה מפריעה או חוסמת את המעבר של בעלי הדירות לחצר. אעיר, בהקשר זה, כי טענת הנתבע לפיה עבודות הגינון בוצעו על ידו עבור הנציגות לבקשתה לא נסתרה על ידי התובעים (עמוד 15 לפרוטוקול שורה 30 וכן עמוד 16 לפרוטוקול). כמו כן,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 273/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

טענת הגב' מנדלבאום לפיה הנתבע שתל עצים אשר צמחו ומגיעים עד לקומת דירתה נראית, על פניה, מופרכת. המדובר בעצים בוגרים שניכר כי ניטעו במקום לפני שנים רבות.

גם אין ממש בטענה כי התקנת הערסל מהווה שימוש ייחודי ברכוש המשותף. בפרט כאשר העידו בפני בעלת דירה (גב' בנצר) ודיירת (גב' שלמון) אשר גם הן עשו שימוש בגינה ובערסל, בין אם ביחד עם הנתבע ובין בלעדיו, כאמור לעיל.

בכל הקשור לקשירת כלב בחצר המשותפת דעתי העקרונית היא כי אין המדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף. קשירת כלב ברכוש המשותף, באופן קבוע, כמוהה כסיפוח השטח בפועל לטובת בעליו של הכלב. שימוש שכזה מונע מאחרים את אפשרות השימוש החופשי ברכוש המשותף וממילא מגביל אותו עד מאוד. אולם, אינני נדרש לקבוע מסמרות בעניין זה מאחר ולא נתבקש כל סעד בעניין וממילא, לא עלה בידי התובעים להוכיח כי הנתבע קושר את כלבו בחצר באופן קבוע על מנת שלא לאפשר גישה לבעלי הדירות לחצר זו.

הגב' מנדלבאום מעידה כי הכלב מנע ממנה גישה לחצר אולם מעדותה עולה כי באותה הפעם שהגיעה לדירת הנתבע, הכלב היה בתוך דירת הנתבע דווקא (עמוד 12 לפרוטוקול שורות 4-1). מעדותה גם עולה כי היא מגיעה לבקר בנכס רק אחת לשנה לערך ולפיכך אין היא יכולה להעיד, באמת, על המצאותו של הכלב באופן קבוע בחצר (עמוד 11 לפרוטוקול שורה 1).

הגב' גולן מעידה כי היא לא הסתכלה למקום של הנתבעים כי "יש כלב שמתנפל". דא עקא, היא לא מתגוררת בדירה כבר מאז שנות ה-60 ודירתה איננה מושכרת ולא נעשה בה כל שימוש (עמוד 10 לפרוטוקול שורות 15, 17 ו-21). גם היא איננה יכולה להעיד על המצאות עקבית של הכלב בחצר.

דווקא התובעים, המתגוררים בבית, יכולים היו להעיד במפורש בהקשר זה אולם טענותיהם בקשר לכך נשמעו בלשון רפה וללא כל ראיה תומכת. למעשה, גם מעדות התובע עולה כי הכלב מוחזק בתוך הדירה דווקא. כך עולה מתיאור "תקיפתו" שלו על ידי הכלב (עמוד 7 לפרוטוקול שורות 29-30). כך גם עולה מהסבריו של הנתבע לאירוע "הנשיכה" שתואר על ידי התובעת בעדותה (ר' עמוד 4 לפרוטוקול שורות 16-18 ועמוד 16 שורות 11-13).

גם מעדויות הגב' בנצר ושלמון לא עולה כי הכלב הוחזק בחצר המשותפת באופן קבוע.

סמכות המפקח ליתן צו הריסה

בכל הקשור לטענת הנתבע בדבר העדר סמכות של מפקח על רישום מקרקעין ליתן צו הריסה, הרי שטיעונו של ב"כ הנתבע בנוגע להוראות סעיף 51(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984 והפסיקה לגביו, אינם רלבנטיים, באשר סמכותו העניינית של מפקח על רישום מקרקעין קבועה בהוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 273/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

אין לי אלא להפנות להלכה אשר נקבעה בע"א 768/80 יוסף לחם נ' אליהו פומרנץ פד"י לח(3) 527 לפיה למפקח סמכות ליתן צו הריסה - "סמכויות המפקח, מבחינה עניינית, נקבעו בסעיף 72 של חוק המקרקעין. לפי סעיף-קטן (ב) באותו סעיף, "סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח". מהוראה זו ברור, שהמפקח רשאי להכריע בסכסוך בעניין הסגת גבול ברכוש המשותף. על-פי הוראת סעיף-קטן (א) של סעיף 72, מוסמך המפקח לדון בכל "סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון..." הוראה זו הסמיכה את המפקח לדון ולהכריע לגבי אותו חלק מהמבנה, שהוקם בחלק הצמוד לדירת המערערים. סעיף 74 אינו מגביל את סמכותו העניינית של המפקח, אלא הוא נותן למפקח "הדן בסכסוך" את כל הסמכויות, שיש לשופט בית-משפט השלום, כאשר זה דן בתביעה אזרחית. על סמכויות של שופט בית-משפט השלום, כאשר הוא דן בתביעה אזרחית, נאמר בסעיף 34 של חוק בתי המשפט: "כל בית משפט הדן בענין אזרחי מוסמך לתת פסק דין הצהרתי, צו עשה, צו לא - תעשה, צו ביצוע בעין וכל סעד אחר, ככל שיראה נכון בנסיבות שלפניו". צו ההריסה, שניתן על-ידי המפקח, הוא צו עשה, ומכיוון שהוא היה מוסמך לדון בסכסוך, שהוא לפניו, הרי, על-פי הוראת סעיף 34 של חוק בתי המשפט, הוא היה מוסמך לתת את צו ההריסה. על-כן אין למצוא כל חריגה מסמכות המפקח, בכך שנתן צו הריסה" (שם בעמ' 531).

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה בחלקה בלבד ומורה כלהלן:

אני מחייב את הנתבע להחזיר את גדר הבטון של המרפסת לקדמותו באופן זה שהגדר תהיה בגובה זהה לכל אורכה מבלי פתח יציאה ישירה לחצר הבית בחזית המרפסת או בצידה הימני (כשהפנים מהדירה לכיוון החצר). בכלל העבודות האמורות אני מחייב את הנתבע להסיר את דלתות הויטרינה המותקנות בחזית המרפסת וכן לפרק את המדרגות בצידה הימני של המרפסת.

יתר הסעדים המבוקשים בכתב התביעה נדחים.

למען הסר ספק אבהיר כי, למעט העבודות האמורות, אינני מחייב את הנתבע לבצע כל עבודה נוספת ובכלל זה אינני מחייבו להרוס ו/או לשנות את הויטרינה המותקנת במרפסת, למעט הסרת דלתות הויטרינה בחזית המרפסת כאמור.

על הנתבע לבצע את האמור לעיל בתוך 45 יום ממועד קבלת פסק הדין.

בהתאם לסמכותי על פי סעיף 130 לחוק המקרקעין אני מורה לרשמת המקרקעין לרשום הערה בספרי המקרקעין על זכויות הנתבע בגוש 7130 חלקה 75 תת חלקה 4 כלהלן: "קיים פסק דין בפני המפקח על רישום מקרקעין בתיק 273/10 בדבר סגירת פתחי יציאה ישירה לחצר".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק 273/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל - אביב

בנוסף אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעים בגין החזר אגרת פתיחת ההליך סך של 601 ₪.

בנסיבות ההליך דנן בהן נדחו מרבית הסעדים הנתבעים ולמעשה נתברר גם כי חלק נכבד מהטענות העובדתיות שנטענו בכתב התביעה אינן נכונות, לא מצאתי לנכון לחייב את הנתבע בהוצאות ההליך.

למעט החזר האגרה כאמור, כל צד ישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בתאריך, י"ט שבט תשע"א, 24 ינואר 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל-אביב